

1501746-38.2022.8.26.0168

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Aline Sugahara Bertaco

Comarca: Dracena

Foro: Foro de Dracena

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 18/08/2022

... comprovar a autoria e a materialidade do crime de tráfico.

Nesse sentido:

'PROVA - Testemunha - Crime de tráfico de entorpecentes - Depoimento prestado por policiais - Validade - Presunção de que, no desempenho de suas funções, agem escorreitamente. A circunstância de ser policial a testemunha não afeta (positiva ou negativamente) o valor probante de sua palavra ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Dracena

Foro de Dracena

3ª Vara

Rua Bolívia, 137, Dracena - SP - cep 17900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501746-38.2022.8.26.0168 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501746-38.2022.8.26.0168

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Éricson Massareli Augusto de Oliveira

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Aline Sugahara Bertaco

Vistos.

Trata-se de ação penal promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face do réu ÉRICSON MASSARELLI AUGUSTO DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, imputando-lhe a prática dos crimes previstos nos artigos 33, "caput", c.c. com os artigos 29 e 40, incisos IV e V, o primeiro e o terceiro da Lei nº 11.343/06 e o segundo do Código Penal, porque no dia 15 de junho de 2022, por volta das 01h40min, na Rodovia Vicinal Engenheiro Byron de Azevedo Nogueira, km 9,1, nesta cidade e Comarca de Dracena/SP, agindo com unidade de desígnios e comunhão de esforços com a adolescente Lívia Maria Ribeiro, transportavam e traziam consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, uma porção prensada, contendo 1001,47g (um mil e um grama e quarenta e sete centigramas do entorpecente vulgarmente conhecido como "crack", e uma porção contendo 954,23g (novecentos e cinquenta e quatro gramas, vinte e três centigramas) do entorpecente vulgarmente conhecido como "cocaina", o que faziam sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A prisão em flagrante do réu foi convertida em prisão preventiva em 15/06/2022 (fls. 92/99).

Foi deferido o pedido de quebra de sigilo de dados e comunicações telefônicas no celular apreendido em poder do réu (fls. 117/118).

Regularmente notificado (fls. 173), o réu apresentou defesa prévia (fls. 158/159).

A denúncia foi recebida em 02/08/2022, ocasião em que foi designada audiência de instrução, debates e julgamento virtual por meio de videoconferência (fls. 167/171).

Durante a instrução criminal foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação, bem como realizado o interrogatório do réu (cf. mídia).

Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais pugnando pela condenação do réu nos exatos termos da denúncia. A defesa, em suma, pugnou pela absolvição do réu por fragilidade probatória. De forma subsidiária, requereu a aplicação do privilegio e da atenuante da confissão espontânea.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, necessária a revisão da capitulação jurídica dada aos fatos narrados na denúncia.

Em que pese a tipificação legal da conduta proposta pela acusação, do crime de tráfico de drogas ter sido praticado com violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo, ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva (art. 33, "caput", c.c. art. 40, inciso IV da Lei nº 11.343/06), observa-se que a descrição dos fatos contida na denúncia corresponde a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06 (sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação).

Isso porque apesar de a denúncia ter capitulado o crime com incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei 11.343/06, constou que o denunciado, agindo com unidade de desígnios e comunhão de esforços com a adolescente Lívia Maria Ribeiro, transportavam e traziam consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, drogas.

Assim, atento à descrição dos fatos narrados na denúncia, é possível ao magistrado fazer nova capitulação, porquanto o réu, no processo penal, defende-se dos fatos descritos na denúncia como crime, e não da capitulação jurídica, que por vezes, pode não estar consentânea com a moldura fática descrita.

Assim, deve-se proceder à emendatio libelli (correção da capitulação contida na denúncia), de acordo com o disposto no artigo 383, caput, do CPP, a fim de apreciar a imputação à luz do tipo penal inserido no artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, incisos V e VI, da Lei nº 11.343/06.

Ressalte-se que a nova definição jurídica não traduz a ideia de que a defesa ficou prejudicada durante a instrução criminal, notadamente porque todos os elementos constitutivos da aludida qualificadora foram descritos de modo expreso na denúncia.

Nesse sentido, é o escólio do renomado jurista, Guilherme de Souza Nucci, in Código de Processo Penal Comentado, 7ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2008, págs. 662 e 663, verbis: "Definição jurídica do fato: é a tipicidade, ou seja, o processo pelo qual o juiz subsume o fato ocorrido ao modelo legal abstrato da conduta proibida. Assim, dar a definição jurídica do fato significa transformar o fato ocorrido em juridicamente relevante... Portanto, neste artigo, o que o juiz pode fazer, na fase da sentença, é levar em consideração o fato narrado pela acusação na peça inicial (denúncia ou queixa), sem se preocupar com a definição jurídica dada, pois o réu se defendeu, ao longo da instrução, dos fatos a ele imputados e não da classificação feita...".

No mérito, a ação penal é procedente.

A materialidade está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 20/23), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 26/27), pelas fotografias das drogas (fls. 28/30 e 52), pelos laudos de constatação provisória de substância entorpecente (fls. 31/35 e 36/40), pelos comprovantes de depósito judicial (fls. 109 e 136), pelos laudos de exame químico toxicológicos definitivos (fls. 126/128 e 129/131), bem como pela prova oral produzida durante a fase de instrução.

Igualmente, a autoria é inconteste e recai sobre o réu.

A testemunha de acusação Lívia Maria Ribeiro disse que o réu a convidou a depoente para ir até Três Lagoas de Uber. Ele enviou mensagem pelo celular. Chegou uma pessoa na esquina que entregou a droga para o réu. Em Três Lagoas o réu usou o

aparelho celular dele. O réu disse para mudar a rota e tinha Polícia que parou. A Polícia encontrou a droga no banco de trás. A depoente estava no banco da frente. Não contribuiu com o transporte da droga. Tinha droga dentro da sua bolsa. Éricson não lhe prometeu nenhum pagamento. Tem 17 anos de idade. Conhece o réu há menos de dois meses. Ele trabalhava com entrega. Não sabe o valor que Éricson ganhou com o transporte da droga. Foram e voltaram no mesmo dia para Três Lagoas (cf. mídia). A testemunha de acusação Dario José Guimarães Neto disse que foi contratado para transportar o réu de Três Lagoas até Dracena. Na época tinha o seu telefone divulgado em várias redes sociais. Acredita que o réu viu seu telefone e entrou em contato. Tinha acabado de chegar de Campo Grande quando o réu lhe telefonou perguntando se poderia fazer uma viagem até a cidade de Dracena. Foi buscar o réu no local indicado e foram para Dracena. O réu estava com uma jovem. A jovem ficaria na cidade de Brasilândia, mas quando chegou na cidade, ela decidiu seguir viagem com o réu. As malas que o réu e a jovem transportavam estavam atrás. Quando chegaram na cidade de Dracena, a Polícia parou o veículo. Foi Éricson que entrou no carro com as bolsas porque a jovem entrou no bar para buscar cerveja (cf. mídia). A testemunha de acusação Fernando Carvalho Abreu, policial militar, disse que na data do fato efetuava uma operação para o combate de tráfico de drogas e próximo ao acesso da Penitenciária de Dracena deparou-se com um veículo HB20. Éricson estava no banco de trás com um quilo de "crack" e quase um quilo de cocaína. O motorista foi identificado como sendo motorista de Uber. Na frente estava a adolescente que confirmou que acompanhou Éricson até a cidade de Três Lagoas/MS e estava ciente do transporte da droga. Foram apreendidos dois celulares, além de uma quantidade de dinheiro em poder do réu. O réu estava lúcido (cf. mídia). (cf. mídia). Em seu interrogatório, o réu ÉRICSON MASSARELI AUGUSTO DE OLIVEIRA confirmou os fatos. Disse que estava no bar cedo. Era nove horas da manhã. Ficou a manhã toda. Chegaram dois rapazes à tarde que chamaram o interrogando para beber. Chegaram ao assunto de drogas. Os dois rapazes perguntaram se o interrogando tinha coragem de buscar droga por dois mil reais em Três Lagoas/MS. Na cidade de Três Lagoas/MS, chegou um cara de carro que lhe entregou a droga. A adolescente não estava com o interrogando, mas estava o esperando. Chamou a adolescente para ir com o interrogando, disse que iria buscar algo, mas não falou o que era. Tinha dois quilos de droga na sua bolsa. Mas depois tirou um quilo e colocou na bolsa da adolescente. Não recebeu nada. Teria que entregar essa droga para uma pessoa atrás do Posto São Paulo, na cidade de Dracena. Não recebeu os dois mil reais do desconhecido que lhe pagaria. Não conhecia os dois rapazes no bar. A adolescente estava com o interrogando no dia a dia por isso a chamou para ir até a cidade de Três Lagoas/MS. Foi de Uber até a cidade de Três Lagoas/MS e voltou com outro motorista de Uber. A corrida deu trezentos reais para ir e mais trezentos reais para voltar. O valor da corrida de Uber foi pago pelos rapazes que conheceu no bar. Não sabe o nome dos rapazes. Foi até a Vila Cássia, na esfiaria, na Vila Cássia. Ficou sentado com a adolescente na Esfiaria quando chegou um cara com carro vermelho e o chamou para ir na esquina. O interrogando foi e pegou a droga. Depois colocou na bolsa. Seu pai e sua mãe tinham falecido. Estava fazendo bicos e ganhava oitenta reais por dia, mas não era direto. É usuário de drogas de "crack" e cocaína. Já foi preso antes por tráfico e Maria da Penha. Estava de regime aberto e faltava um ano e dez meses. Tem um filho de catorze anos que é cuidado pela mãe (cf. mídia).

De toda instrução, vislumbro que confissão judicial do réu está em consonância com o arcabouço probatório produzido.

O conjunto probatório produzido indica que a substância entorpecente apreendida pertencia ao réu e destinavam-se à traficância, considerando a natureza e a expressiva quantidade de substância, a saber: 01 (uma) porção na forma de "crack" com massa líquida de 1001,47 g (um mil e uma grama e quarenta e sete centigramas) (cf. Auto de exibição e apreensão fls. 26/27; laudo provisório de fls. 36/40 e laudo pericial de exame químico-toxicológico definitivo de fls. 126/128), bem como outra porção da mesma substância na forma de "cocaína" com massa líquida de 954,23g (novecentos e cinquenta e quatro gramas e vinte e três centigramas) (cf. Auto de exibição e apreensão fls. 26/27; laudo provisório de fls. 31/35 e laudo pericial de

exame químico-toxicológico definitivo de fls. 129/131).

Segundo a prova oral, o réu foi contratado para buscar drogas no município de Três Lagoas/MS, pelo qual receberia em troca a quantia de R\$ 2.000,00 (dois mil reais). O réu convidou a adolescente Lívia para acompanhá-lo no ilícito. Chegando ao local, após se apoderar das drogas, contatou o motorista Dário José Guimarães Neto para retornar ao município de Dracena/SP. Todavia, durante a abordagem policial rotineira, constatou-se que a adolescente estava no banco dianteiro do passageiro e o réu no banco traseiro. Durante a vistoria, foi apreendida a mochila da adolescente contendo uma porção de "cocaína", com massa líquida de 954,23g (novecentos e cinquenta e quatro gramas, vinte e três centigramas), além de um aparelho celular da marca SAMSUNG, cor vermelha. Ainda foi apreendida uma mala de propriedade do réu contendo porção de "crack", sob forma de tijolo com massa líquida de 1001,47g (um mil e uma grama e quarenta e sete centigramas), além de uma quantia de R\$ 25,00 (vinte e cinco reais) e um aparelho celular da marca MOTOROLA, cor azul.

Ressalte-se que os testemunhos dos Servidores Policiais em Juízo são suficientes para, com as demais provas carreadas aos autos, sobretudo os laudos definitivos de substância entorpecente (fls. 126/128 e 129/131), comprovar a ocorrência do fato típico e embasar um decreto condenatório ao réu, vez que dotados de fé pública e idoneidade em suas alegações, mormente por terem corroborado os depoimentos na fase inquisitorial.

Não há razão suficiente a invalidar o depoimento dos Policiais, por suspeitos ou impedidos de deporem, só porque ostentam essa qualidade, pois seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu agente e, depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse taxado de suspeito.

A jurisprudência é firme no sentido de que, aliado a outras provas, o depoimento dos policiais é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de tráfico.

Nesse sentido:

'PROVA - Testemunha - Crime de tráfico de entorpecentes - Depoimento prestado por policiais - Validade - Presunção de que, no desempenho de suas funções, agem escorreitamente. A circunstância de ser policial a testemunha não afeta (positiva ou negativamente) o valor probante de sua palavra Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força persuasória nem o inquina de suspeição Afere-se-lhe o mérito e mede-se-lhe o grau de confiabilidade, segundo os critérios ordinariamente aplicados - Recurso parcialmente provido'. (Apelação Criminal n. 993.07.105623-5 - Sumaré - 9ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Souza Nery 06.08.08 - V.U. - Voto n. 13111)

'TÓXICO - Tráfico - Condenação baseada em depoimentos policiais - Depoimento seguro e coerente ao incriminar o acusado - Palavra destes, que somada as demais provas, merece total credibilidade - Presença, ademais, de testemunhas civis - Condenação mantida - Recurso não provido. O depoimento exclusivo de policiais é de toda validade quando coerente e corroborado pelas demais provas coligidas nos autos'. (Apelação Criminal n. 181.618-3 - Tietê - 4ª Câmara Criminal - Relator: Augusto Marin - 12.06.95 - V.U.)" (TJSP, Apelação nº 3005426-36.2013.8.26.0082, 10ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. FRANCISCO GALVÃO BRUNO, j. 31.03.2016).

Ademais, as versões dos policiais militares foram corroboradas pelo auto de exibição/apreensão (fls. 26/27) comprovando a apreensão das drogas, pelos laudos periciais provisórios (fls. 31/35 e 36/40) e laudos definitivos das drogas (fls. 126/128 e 129/131) que atestaram positivo para "COCAÍNA".

Nesse contexto, a julgar pela expressiva quantidade, natureza (cocaína) e a forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes apreendidas, a saber, 01 (uma) porção na forma de "crack" com massa líquida de 1.001,47 g (um mil e uma grama e quarenta e sete centigramas), além de outra porção da mesma substância na forma de "cocaína" com massa líquida de 954,23g (novecentos e cinquenta e quatro gramas e vinte e três centigramas) (cf. auto de exibição e apreensão fls. 26/27), denotam, às claras, sua predisposição: a entrega a consumo de terceiros, o que torna inexorável a adequação típica da conduta ao crime previsto no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

A jurisprudência é firme nesse sentido:

"TÓXICOS - Tráfico - Agentes presos em flagrante quando transportavam 561 gramas de maconha - Ausência de prova direta da finalidade mercantil - Irrelevância à caracterização do delito. Não é apenas a quantidade de substância entorpecente que deve influir no julgamento, mas o conjunto de fatores expressamente previstos no artigo 37 da Lei nº 6.368/76. Até porque, segundo ponderável corrente jurisprudencial, para a configuração do delito de tráfico, na forma consumada, não é indispensável que o agente efetue a comercialização da droga. Basta que a possua, guarde ou a tenha em depósito, sobretudo em grande quantidade, circunstância denunciadora da mercancia. - Recurso conhecido e provido." (TJMG, Acr nº 263.616-5/00, 1ª Câmara Criminal, Relª Desª MÁRCIA MILANEZ, j. 07.05.2002).

Ainda, importante consignar que, em se tratando o tipo penal de tráfico de drogas de conteúdo variado ou misto alternativo, qualquer das condutas descritas tipifica o delito. Dessa forma, ainda que o réu não tivesse sido flagrado comercializando as substâncias entorpecentes, o simples trazer, guardar drogas é suficiente para que se configure o tráfico ilícito de drogas, sendo dispensável a oitiva de eventuais compradores usuários.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado no Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio artigo 37 da Lei Antitóxicos dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes dos agentes." (RT 584/347).

Portanto, para caracterizar o crime de tráfico de entorpecentes, o agente não necessariamente precisa ser flagrado em efetivo comércio ou auferindo lucro, bastando que se identifique algum dos núcleos elencados no tipo penal.

De outra parte, a circunstância de ser o réu usuário de drogas não afasta a caracterização do crime de tráfico de drogas, pois nada impede que a figura de usuário e traficante recaia sobre a mesma pessoa.

No mesmo sentido:

"TÓXICOS - Tráfico - Agentes presos em flagrante quando transportavam 561 gramas de maconha - Ausência de prova direta da finalidade mercantil - Irrelevância à caracterização do delito. Não é apenas a quantidade de substância entorpecente que deve influir no julgamento, mas o conjunto de fatores expressamente previstos no artigo 37 da Lei nº 6.368/76. Até porque, segundo ponderável corrente jurisprudencial, para a configuração do delito de tráfico, na forma consumada, não é indispensável que o agente efetue a comercialização da droga. Basta que a possua, guarde ou a tenha em depósito, sobretudo em grande quantidade, circunstância denunciadora da mercancia. - Recurso conhecido e provido." (TJMG, Acr nº 263.616-5/00, 1ª Câmara Criminal, Relª Desª MÁRCIA MILANEZ, j. 07.05.2002).

Para ilustrar, aponto as lições de LUIZ FLÁVIO GOMES: "Para se concluir pela prática do crime de tráfico, não basta, em princípio, a quantidade (ou qualidade) da droga apreendida. Deve-se atentar, ainda, para outros fatores, tais como o local e suas condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente (art. 52, I)" (In EL TASSE, Ade ler. Al. Legislação Criminosa Especial. VI. 6. São Paulo: Editora RT, 2009, p. 197)."

A propósito, convém transcrever que a decisão publicada na RT 546/327, para a confecção de uma porção individual de cocaína é necessário 0,01 grama ou 0,1 grama, a depender se consumida por via endovenosa ou por aspiração, o que indica que a cocaína que estava em poder dos réus, cujo peso totalizava 1.955,7g (um mil novecentos e cinquenta e cinco gramas e sete centigramas), era suficiente para a confecção de mais de 195.000 (cento e noventa e cinco mil) porções individuais! Isso deriva do seguinte entendimento: "por exemplo, no caso da cocaína consumida por via endovenosa uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração, a dose corresponde a 0,1 grama; diferentemente, em um cigarro de maconha há 0,33 gramas da citada substância entorpecente" (Legislação Penal Especial, Editora Atlas, 3ª

edição, São Paulo, 2000, citando julgado colacionado na RT 546/327).

Com efeito, não prospera a tese de que a droga apreendida se destinava ao consumo pessoal do réu, motivo pelo qual fica afastada a pretensão de absolvição por fragilidade probatória.

Assim, os elementos informativos colhidos na fase inquisitória, aliado às provas que se produziu em Juízo, são suficientemente harmônicos e aptos a ensejar a condenação do réu pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei de Drogas, pois demonstrado que, na espécie, o réu infringiu a norma do artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06, por, ao menos, transportar e trazer consigo substância entorpecente, cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, bem como em vista a natureza, a expressiva quantidade e a forma de acondicionamento da droga, incompatível com o porte para consumo pessoal, tudo indicando claramente o tráfico.

Outrossim, comprovado pelos depoimentos colhidos em Juízo, que o crime de tráfico de drogas foi realizado entre Estados da Federação, fazendo incidir a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06, porque o acusado transportou a droga da cidade de Três Lagoas, situada no Estado de Mato Grosso do Sul, com destino a cidade de Dracena/SP, porém, foi abordada pelos policiais militares nesta Comarca de Dracena/SP.

Tem-se, ademais, que o crime de tráfico de drogas teve o envolvimento da adolescente Lívia Maria Ribeiro, nascido em 25/02/2005, com 17 (dezessete) anos de idade (cf. documento de fls. 16), caracterizando a incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06.

Ficou devidamente configurado o concurso de agentes pela prova oral produzida, em razão da versão dos policiais militares em Juízo que afirmaram que o acusado Éricson Massarelli Augusto de Oliveira juntamente com a menor Lívia Maria Ribeiro, transportavam e traziam consigo droga para fins de tráfico.

A propósito, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça que "caracteriza-se o concurso de agentes quando há a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, sendo prescindível a identificação do co-réu" (STJ; HC 108.289; Proc. 2008/0126931-1; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Paulo Benjamin Fragoso Gallotti; Julg. 28/10/2008; DJE 17/11/2008).

Nesse contexto, convém frisar que para a caracterização do concurso de agentes é irrelevante identificar qual dos agentes praticou o núcleo do tipo. Isso porque o apoio prestado, seja como autor seja como partícipe, pode servir para configurar o concurso de agentes.

Como é cediço, quando mais de um agente se reúne para a prática de um crime é natural que se torne mais acessível a concretização do delito.

Assim, não prospera a tese defensiva de fragilidade probatória, tendo em vista as circunstâncias do flagrante, a natureza e a expressiva quantidade da substância entorpecente apreendida.

Deve-se, também, reconhecer que a prova colhida, principalmente em razão da versão apresentada pela adolescente Lívia Maria, é firme o suficiente para se concluir que o aparelho celular modelo MOTOROLA, cor azul, apreendido em poder do réu Éricson Massarelli Augusto de Oliveira era utilizado para a prática do crime de tráfico de drogas, pois o aparelho foi utilizado pelo réu para manter o contato com a adolescente e com o motorista de Uber, razão pela qual deve ser declarado perdido. Portanto, demonstrada a autoria e materialidade do delito, bem como a ausência de qualquer circunstância que exclua o crime ou isente o agente de pena, mostra-se de rigor a procedência da pretensão acusatória.

Em homenagem ao princípio constitucional da individualização da pena (CRFB, art. 5º, XLVI), passo à necessária dosimetria.

Na primeira fase da dosimetria da pena, atento às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu ostenta de maus antecedentes, pois apresenta mais de uma condenação com trânsito em julgado, na qual foi condenado por sentença irrecorrível pela prática do crime de lesão corporal e ameaça (Autos 0000765-20.2021.8.26.0168 - fls. 62, com data de trânsito em julgado no dia 25/11/2016).

Ademais, há previsão legal expressa permitindo ao juiz, na fixação das penas,

considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente (artigo 42 da Lei nº 11.343/06).

Assim, considerando uma circunstância judicial negativa e diante da natureza (cocaína) e expressiva quantidade de droga apreendida, a saber, 01 (uma) porção na forma de "crack" com massa líquida de 1.001,47g (um mil e uma grama e quarenta e sete centigramas), além de outra porção da mesma substância na forma de "cocaína" com massa líquida de 954,23g (novecentos e cinquenta e quatro gramas e vinte e três centigramas), o que evidencia o intenso (e demais graves consequências) tráfico a ser praticado e trouxe maior grau de censurabilidade à conduta do réu, fixo a pena-base acima do mínimo legal, elevando-a em 1/3 (um terço), totalizando em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, A propósito:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. DESFAVORÁVEIS. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. A motivação adotada pelo Tribunal a quo para fixar a pena-base acima do mínimo legal mostra-se adequada e suficiente. Foram indicados elementos concretos que demonstram serem desfavoráveis as circunstâncias do crime, ressaltada a grande quantidade de entorpecentes apreendida (96 papelotes de cocaína). 2. Em consequência, não se mostra possível a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, tendo-se presente que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal e a pena imposta é de 8 (oito) anos. 3. Habeas corpus denegado. (STJ - HC: 124554 MS 2008/0282818-9, Relator: Ministra Maria Thereza De Assis Moura, DJ: 22/08/2011, 6ª T, Data de Publicação: DJe 31/08/2011)".

"(...) No crime de tráfico de drogas, não há ilegalidade no aumento da pena-base se nas instâncias ordinárias esclareceu-se ter sido grande a quantidade de droga apreendida (no caso, 18 pedras e 4 pedras grandes de crack, 65 papelotes de cocaína, 01 bucha de maconha) e variada a natureza. O art. 42 da Lei n.º 11.343/06 é expresso no sentido de que o "juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto". (STJ - HC: 214180 ES 2011/0172672-2, Relator: Ministra Laurita Vaz, DJ 22/10/2013, T5 DJe 05/11/2013)".

Na segunda fase de dosimetria, em que pese a confissão judicial do acusado, considerando a preponderância da reincidência (art. 61, I, CP) sobre aquela atenuante, pois o réu possui condenação criminal definitiva pela prática do crime de tráfico de drogas e receptação (Autos 0000026-47.2021.8.26.0168 - fls. 61/62, com trânsito em julgado no dia 24/03/2017), tratando-se de reincidente específico, compenso de forma proporcional e exaspero a reprimenda de forma proporcional, em 1/6 (um terço), totalizando 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa.

Na terceira fase do cálculo da pena, incide as causas de aumento de pena prevista no artigo 40, incisos V e VI, da Lei nº 11.343/06, pois cabalmente comprovado pelas provas colhidas que o crime de tráfico de drogas foi praticado pelo acusado entre os Estados da Federação (Três Lagoas/MS e Dracena/SP) e com o envolvimento da adolescente Lívia Maria Ribeiro (17 anos), motivo pelo qual elevo a pena anteriormente alcançada em 1/3 (um terço), atingindo o patamar de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias e 1036 (um mil e trinta e seis) dias-multa.

Vale ressaltar que o presente caso não se subsume as hipóteses de aplicação do privilégio previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Isso porque tal privilégio foi previsto aos agentes primários que possuem bons antecedentes e não se dediquem às atividades criminosas nem integrem organização criminosa, o que não é o caso, já que o réu é reincidente específico, pois possui condenação criminal anterior com trânsito em julgado pela prática do mesmo crime de tráfico de drogas (Autos 0000026-47.2021.8.26.0168 - fls. 61/62). Ademais, no caso presente, diante da natureza (cocaína) e expressiva quantidade de substância entorpecente (1.001,47g de "crack" e 954,23g de cocaína), tudo a indicar a sua dedicação às atividades criminosas, fazendo do tráfico ilícito um modo de vida, o que impede a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em razão da situação concreta do delito, de

extrema gravidade. Se essa quantidade de droga entrasse em circulação, certamente destruiria a vida de muitos jovens e suas respectivas famílias.

A propósito, é pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça que a quantidade, a diversidade e a natureza da droga justificam a não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Confira-se:

"PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. VIA INADEQUADA. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE DA DROGA. AFASTAMENTO. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. REGIME MAIS BRANDO. FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. (...) AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL DE N.º 1444115-3 3ª CCRIMINAL 3. Caso em que a expressiva quantidade de droga encontrada (120kg de maconha) demonstra a dedicação do paciente às atividades criminosas e afasta a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, enfraquecendo a alegação de ocorrência de bis in idem. Precedentes do STF. (...) (STJ, HABEAS CORPUS Nº 308.682 - MS (2014/0293393- 8), rel. Min. Gurgel De Faria, julg. 08/09/2015)."

Assim, torno definitiva a pena em 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 1.333 (um mil, trezentos e trinta e três) dias-multa.

Baseado no critério da situação econômica do réu, arbitro cada dia-multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Fixo o regime fechado para início do cumprimento de pena, nos termos do artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90 e do art. 33, § 2º, alínea "a", c.c. art. 59 do Código Penal, em razão da reincidência, dos maus antecedentes e do quantum de pena aplicada ao réu, aliado ao fato de que o tráfico ilícito de substância entorpecente é conduta das mais deletérias, que atenta contra a saúde e até mesmo a vida de considerável parcela da população, composta basicamente por jovens adolescentes, os quais, uma vez iniciados no vício, raramente dele conseguem se livrar. Além disso, se constitui em porta aberta para o cometimento de outros crimes, notadamente voltados contra o patrimônio, sabido que não raro usuário destituído de capacidade econômica subtrai bens alheios para conseguir dinheiro para sustentar o vício. Cuida-se, ademais, de conduta equiparada a crime hediondo. Mesmo que, em alguns casos, possa não ser mais considerado hediondo, ainda assim o crime de tráfico é sempre muito grave, comportando, dessarte, o regime inicial fechado. Tudo, enfim, a justificar maior rigor na retribuição.

Considerando o montante de pena aplicado, bem como que o réu ostenta de maus antecedentes, conduta social reprovável e reincidência, verifico que não se fazem presentes os requisitos descritos no artigo 44 do Código Penal em relação à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Pelos mesmos motivos, não é cabível o benefício da suspensão condicional da pena (art. 77, CP). Ademais, tais institutos, além de se mostrarem incompatíveis com o regime fechado fixado para cumprimento da pena, não se mostram socialmente recomendáveis e suficientes à repressão do crime de tráfico de drogas.

Ante o exposto e considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido de ação penal, e assim o faço para CONDENAR o réu ÉRICSON MASSARELLI AUGUSTO DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1036 (um mil e trinta e seis) dias-multa, fixados estes em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos, por estar incurso no artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, incisos V e VI, da Lei nº 11.343/06.

Considerando presentes os requisitos e fundamentos que levaram à decretação da prisão preventiva do acusado, aos quais faço referência a fim de evitar repetições desnecessárias (fls. 92/99), bem como considerando que a necessidade da prisão cautelar foi realçada pelo decreto condenatório e regime de pena ora definidos, em se tratando de réu reincidente específico, MANTENHO a custódia cautelar do réu, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Transitado em julgado: a) expeça-se guias de execução e formem-se os autos de execução de pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; b) oficie-se



ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral por conta da suspensão dos direitos políticos do apenado, conforme disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, e na Súmula 09 do Tribunal Superior Eleitoral; c) oficie-se a Delegacia de Polícia e ao Instituto de Criminalística, autorizando a imediata destruição dos entorpecentes nos termos previstos em lei, remetendo-se auto competente. Tendo em vista que o artigo 91, inciso II, do Código Penal, juntamente com o artigo 63, da Lei 11.343/06, estabelece que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decreto o perdimento do aparelho celular da marca MOTOROLA apreendido em poder do réu (cf. autos de exibição e apreensão a fls. 26/27) em favor da União. Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGA (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis.

De outra parte, não comprovada a origem ilícita, determino a restituição imediata do valor de R\$ 25,00 (vinte e cinco reais) em espécie em favor do réu.

Transitada em julgado, oficie-se à Delegacia de Polícia e ao Instituto de Criminalística, autorizando a destruição das amostras da substância entorpecente guardadas para contraprova, nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/06, remetendo-se auto competente.

Custas na forma da lei.

Oportunamente, intime-se o réu para efetuar o pagamento da multa. Condene o réu, ainda, ao pagamento das custas processuais, observando-se eventual condição de beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Considerando que o réu foi patrocinado por advogado dativo, defiro a ele os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Anote-se.

Não obstante o condenado ser beneficiário da assistência judiciária gratuita, de acordo com o artigo 804 do Código de Processo Penal, o mesmo fica obrigado ao pagamento de custas processuais. Tal obrigação, contudo, ficará suspensa enquanto perdurar o estado de pobreza do assistido, pelo prazo de 05 (cinco) anos, quando então a obrigação estará prescrita, conforme estabelece o artigo 12 da Lei nº 1.060/50.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Cumpra-se.

Dracena, 18 de agosto de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Aline Sugahara Bertaco

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA